



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

תובעים	1	לוי זהבה
	2	לוי יעקב
באמצעות ב"כ: עו"ד צביקה ציפוק גולדנהירש 24 פתח תקווה, מיקוד 4926235, טל' 03-9313990, פקס 03-9346110		
נתבעים	נגד	
	1	ברק זהר,
	2	ברק שרון
	3	הורן יניב בצלאל,
	4	הורן גלית,
	5	פורת ישי,
	6	פורת יעל,
	7	עובד יצחק,
	8	עובד ענת,
	9	מרגלית אורן,
	10	שחר רבקה,
	12	צימברוביץ חיה לאה
מיכל לייב כץ 29 פתח תקווה באמצעות ב"כ: עו"ד אהוד פורת / אהרוני אורן שאול המלך 8 תל אביב, מיקוד 64733, טל' 03-7540505, פקס 03-7540504		



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

א. כללי

1. עסקינן בבית משותף המצוי ברחוב מיכל לייב כץ 29 פתח תקווה, והידוע גם כגוש 6386 חלקה 247 (להלן: "**הבית המשותף**" או "**הבית**").

הבית המשותף כולל שמונה תתי חלקות.

2. התובעים הם המחזיקים מטעם הבעלים בדירה בבית הידועה כתת חלקה 7, כאשר לדירה זו שלוש הצמדות (המסומנות באותיות ב', ג' ו-ט'). הצמדה ט' היא הצמדה של גג בשטח של 131 מ"ר, ואילו הצמדות ב', ג' הן הצמדות של קרקע בשטח של 11.5 מ"ר (כל אחת).

חלקה היחסי של תת חלקה זו ברכוש המשותף הוא 50/218.

3. הנתבעים הם הבעלים של יתר דירות הבית.

4. הבית המשותף נרשם בפנקס הבתים המשותפים בשנת 1982 וקיים לו תקנון מוסכם (להלן: "**התקנון**").

5. התביעה שבפניי היא תביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעים לחתום על הבקשה להיתר בנייה (להלן: "**הבקשה להיתר**"), שהגישו התובעים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית פתח-תקווה (להלן: "**המוסד התכנוני**"), וזאת על רקע התקנון החל על הבית.

6. במסגרת התביעה מבוקש כי לנוכח סירוב הנתבעים לחתום על בקשת התובעים להיתר בנייה על הגג, יש להורות כי בא כוחם בהליך זה יהא מורשה לחתום בשם הנתבעים על הבקשה להיתר כמי שנתנו הסכמתם לו.

7. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, עיינתי במלוא החומר המצוי בתיק ושקלתי את הטענות, מצאתי לקבל את התביעה.

טרם שאפרוס את נימוקי הכרעתי, אשטח תחילה את תמצית טענות הצדדים.

ב. תמצית טענות התובעים

8. לתובעים זכויות בנייה אשר הוקנו להם בתקנון לטובת הדירה וההצמדה שבבעלותם. לפיכך, זכותם למצות את זכויות הבנייה שניתנו להם.

9. התובעים הגישו בקשה להיתר בנייה מהמוסד התכנוני בעיריית פתח-תקווה, וזו השיבה כי אין מניעה שהבקשה תתקבל, בכפוף לחתימת כל בעלי הזכויות במקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. לשיטת התובעים, לפי ס' 2ב לתקנון מוקנית להם הזכות לבנות ו/או לפצל ו/או לנצל כל זכות בנייה שקיימת לדירתם ולמוצמד אליה (הגג המסומן באות ט' בתשריט, ואם יבנו עליו - גם לגבי גגות החדרים) על פי התב"ע.

11. ביום 23.1.2020 נתקבל מכתבה של האדריכלית הגב' מיכל ראבד, מחברת א.מ. מזרחי אדריכלות והנדסה בע"מ (מטעם התובעים) ובו קביעתה כי בבית המשותף נותרו 114 מ"ר לניצול (כולל שטחי חדרים על הגג) + שתי יחידות דיור ביחס להיתר, אך במהלך ניהול ההליך, הנ"ל תיקנה את עמדתה וציינה (במכתב מתקן מיום 13.9.2020) כי היקף יתרת המ"ר לניצול עומד על 60 מ"ר בלבד.

12. התובעים טענו תחילה כי אין מניעה חוקית לביצוע פיצול של יחידה 7, אולם בדיון שהתקיים ביום 24.6.2020 חזרו בהם מטענתם זו ולפיכך אין עוד צורך להידרש אליה.

13. לנוכח סירוב הנתבעים לחתום על הבקשה להיתר, עותרים התובעים בתביעה זו לאכיפת התחייבות הנתבעים כאמור בס' 2ב לתקנון ובתוך כך להסמיק את בא כוח התובעים, עו"ד ציפוק, לחתום בשמם על הבקשה להיתר (כמי שנתנו הסכמתם לכך).

14. על פי הדין – לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות לשם הצמדת זכויות בנייה יחסיות (קרי: שיוך זכויות הבניה לכל דירה לפי חלקה של כל דירה ברכוש המשותף) לכן ציון עובדה זו בתקנון מיותרת לכאורה. עובדה זו משליכה גם על הפרשנות הראויה של התקנון.

15. על התקנון – כהסכם לכל דבר – להתפרש לפי אומד דעת הצדדים, וככל שלא ברורה משמעותו מתוך לשונו אזי יש לפרשו מתוך נסיבות כריתתו. מאחר שבתקנון מופיעה המילה "זכות", הן ביחס לזכויות קיימות והן ביחס לזכויות עתידיות ("אם ייבנו חדרים על שטח גג זה, הזכות היא גם לגבי גגות החדרים"), מכאן, שניתן ללמוד על ויתור בעלי הדירות על זכותם גם ביחס לזכויות בנייה עתידיות. יצוין כי גם פירוש דווקני של לשון התקנון יוביל למסקנה זוהה.

תמצית טענות הנתבעים

16. פרשנות התובעים לס' 2ב לתקנון שגויה.

התובעים אינם מורשים לנצל את מלוא זכויות הבניה במקרקעין ולחרוג מחלקם היחסי ברכוש המשותף. כמו כן, הם אינם רשאים להגדיל את מס' הדירות בבית משום שהדבר מהווה פגיעה חמורה בזכויותיהם הרכושיות, הקנייניות והתקנוניות של הנתבעים.

17. זכויות בנייה הן נכס משותף הנמצא בבעלות משותפת, וויתור עליהן צריך שיינתן בתקנון באופן מפורש או בהסכמה מלאה של יתר בעלי הדירות. כפי שנקבע בע"א 5043/96 נחמיה גלמן נ' עזרא הררי-רפול, נד(3) 389 (2000), וכן בע"א 11965/05



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, פרופסור (נבו, 27.08.2009), ויתור מפורש או הסכמה כאמור לא ניתנו.

18. התובעים רשאים לנצל זכויות בנייה כדי חלקם היחסי ברכוש המשותף (50/218 בלבד), המהווים 26.12 מ"ר מתוך זכויות הבנייה של הבית. הנתבעים לא זכאים למלוא זכויות הבנייה על הגג המוצמד.

19. בת"א (שלום ירושלים) 20246/00 **גלעדי יצחק נ' גלעדי אברהם** (נבו, 26.03.2007), נקבע כי ניווד זכויות בין בעלי דירות בבית אפשר שיעשה על ידי התניה בתקנון או בחוזה. הצמדה של גג אין פירושה מניה וביה הקניית הרשות לבנות עליו ללא הסכמת בעלי הדירות. לשם בניה על גג צמוד נדרשת הסכמה של יתר בעלי הדירות לבנייה ולא תתקבל הסכמה משתמעת.

20. לחילופין, לא נקבע בתקנון כי התובעים רשאים לנצל זכויות בנייה עתידיות שאושרו בתכניות שייכנסו לתוקף לאחר רישום הבית המשותף. פרשנות סבירה לתקנון תאפשר לתובעים לנצל זכויות בנייה על הגג, ככל שאלה לא נוצלו, רק בגין תכניות שאושרו עד לחודש מרץ 1982 (שהוא המועד בו נרשמו צו הבית המשותף והתקנון המוסכם).

21. הואיל ולזכויות הבנייה ערך כלכלי וניצולן על ידי בעל דירה אחד בבית מפחיתה את שווי דירות הנתבעים אזי יש לפרשו בצמצום. שכן פירוש מרחיב יש בו כדי להביא לירידת ערכן של שאר הדירות בבית.

22. הוספת שתי יחידות דיור על הגג תייצר שינוי מהותי באופי וחזות הבניין, תגרום לעומס גדול יותר על התשתיות, עלולה לסכל פרויקט תמ"א 38 עתידי (הכולל בניית דירות חדשות על הגג) ותביא לצפיפות ולמטרד עבור שאר הדיירים.

23. התקנון אינו מאפשר פיצול הדירה הקיימת לשתי יחידות דיור.

ס' 2ב לתקנון לא כולל בניית דירה נוספת, אלא אך בניית חדרים נוספים להרחבת הדירה הקיימת.

24. זאת ועוד, ביחס לבניית יחידות חדשות קיימת חובה בתב"ע לחניות, שבמידה ויותקנו, יהא זה על חשבון הרכוש המשותף, ולכך מעולם לא הסכימו הנתבעים.

25. כמו כן, לשם בניית יחידות חדשות יידרשו עמודי תמיכה שייבנו על הקירות החיצוניים של הבית, שלא הוצמדו לדירת התובעים ושהנתבעים לא הסכימו לבנייתם.

26. כבר בשנת 2013 הביעו הנתבעים את התנגדותם הנחרצת לבקשת התובעים לבנות על הגג והבקשה נסגרה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. לשיטת הנתבעים, התקנון מתיר לתובעים לבנות על הגג ללא הסכמת יתר בעלי הדירות ולנצל את זכותם **בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף בלבד**, אך הם אינם רשאים לנצל זכויות בניה בהיקף החורג משיעור חלקם היחסי ברכוש המשותף. לפיכך, רשאים הנתבעים לנצל את חלקם היחסי (בהתאם לחלקם ברכוש המשותף) של זכויות הבנייה שנותרו לבית. הא ותו לא.

28. התובעים לא הניחו תשתית עובדתית מספקת להוכחת טענותיהם, רבות זכותם בדירה, ואף הסתירו מסמכים רלוונטיים.

29. פרשנות מרחיבה של התקנון תפגע בתכלית הכלכלית המשותפת, ולכן יש לפרשו בצמצום.

ג. מהלך הדיון:

30. ראשיתה של תביעה זו בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין שבפתח תקווה. שם נערך דיון מקדמי ביום 24.6.2020 ובו התקבלה החלטת המפקחת ארפי מוראי, המורה לתובעים להמציא בפניה אישור של מוסד התכנון הרלוונטי לעניין היקף זכויות הבנייה בבית המשותף, וכן תיק המידע האחרון במוסד התכנון.

עוד הוחלט בדיון הנ"ל על מחיקת הנתבעים 10-11 מכתב התביעה עקב פטירתם. כך, שבכפוף להמצאת אסמכתה בדבר היות הגב' שחר רבקה יורשתם, תבוא היא תחתם (גב' שחר רבקה נרשמה כבעליה של תת חלקה 8 ועל כן יש לראות בה כנתבעת מס' 10).

31. ביום 14.9.20 המציאו התובעים את תיק המידע האמור ממנהל ההנדסה של עיריית פתח תקווה, שמספרו 20200786 (להלן: "**תיק המידע**").

32. התובעים צירפו לתיק המידע מכתב מאת הגב' ראבד (להלן: "**המכתב השני**") ובו נכתב כי בהתאם לתיק המידע "ניתן להקים חדרים על הגג בשטח של עד 60 מ"ר...", וזאת בהנחה שטרם מומשו חלק מזכויות הבנייה בהיתר קודם.

33. ביום 14.9.20 וביום 16.9.20 ניתנו החלטות נוספות של כב' המפקחת ארפי מוראי לפיהן על התובעים להבהיר מהם כלל זכויות הבנייה בשטח הגג ואת שיעור הזכויות המנוצלות.

34. ביום 16.9.20 וביום 21.9.20 הודיעו התובעים כי אכן נעשתה בנייה של כ-20 מ"ר ע"י הקבלן שבנה את הבית, וככל שהעירייה לא תאפשר ו/או יסרבו הדיירים למתן הסכמה לפיצול דירת התובעים לשתי יחידות נוספות, הרי שנותרו כ-40 מ"ר לניצול התובעים.

35. ביום 22.9.20 הוגשה תגובת הנתבעים להודעת התובעים ובה הודגש כי לפי שיטתם ובהתאם לתב"ע ולמכתבה השני של הגב' ראבד, רשאים התובעים לנצל רק את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חלקם היחסי בזכויות הבנייה על הגג, כך שכעת נותרו לרשותם 9.17 מ"ר בלבד (50/218 * 40 מ"ר) ורק עבור בנייה שאינה מהווה דירה נפרדת.

36. עקב מינויה של כב' המפקחת ארפי מוראי כמפקחת בכירה ת"א נותב התיק לכב' המפקח מאיר פורת, אשר בהחלטה מיום 20.5.21 פסל עצמו מלדון בהליך בשל קרבה משפחתית לנתבעים 5-6. עקב כך, הועבר התיק לדיון בפניי.

37. ביום 7.2.22 נערך דיון הוכחות במהלכו נחקרו מר רועי לוי (בנה של התובעת 1) ומר שרון ברק (הנתבע 2). התובעים הסכימו, כאמור, כי לאור הוראות התקנון הם אינם רשאים לפצל דירתם, אך הם עומדים על כך שייקבע כי על פי פרשנות התקנון, זכויות הבנייה הניתנות למימוש על הגג או שיווצרו בעתיד שייכות לנתבעים באופן בלעדי, כך שלרשותם עומדים כ-40 מ"ר לבנייה.

בתום הדיון נקבעו מועדים להגשת הסיכומים; משאלו הוגשו, נדרשת אני להכרעה בסוגיה.

ה. המסגרת הנורמטיבית

זכויות בנייה, מהן?

38. המונח "זכויות בנייה" מוזכר בסעיף 71 ב (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**" או "**החוק**") ומגדיר כ"**זכויות לבניה בבית משותף לפי תכנית בת-תוקף כמשמעותה בפרק ג' לחוק התכנון והבניה**".

39. בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992, נקבעה דרך לחישוב השטחים המותרים לבנייה במקרקעין לפי תכניות, בדרך של "אחוזי בנייה" המגלמים את היחס שבין היקף הבנייה לבין שטח המקרקעין. דהיינו, הגדרת זכויות הבנייה היא קביעת השטח הכולל המותר לבנייה במקרקעין.

40. מקובל גם לראות ב"זכויות הבנייה" כהיתר הניתן על ידי הוועדות לתכנון ולבנייה, הקובע על כמה אחוזים משטח המקרקעין ניתן לבנות.

האם זכויות בניה הן "רכוש משותף" או "נכס משותף" והאם הן ניתנות להעברה?

41. אין ספק כי זכויות, כפי שמשמע משמן, אינן חלק פיזי מן הבית המשותף ולפיכך הן גם לא עולות כדי "רכוש משותף" כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין.

מקובל לראות בזכויות בניה כ"נכס" המצוי בבעלות משותפת כאשר, ככלל, חלקו היחסי של כל בעל דירה בהן הוא כחלקו ברכוש המשותף [ע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר (נבו, 23.3.05)] להלן: "**עניין שטרייכר**".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זכויות בניה, עשויות להיות מושא להסכמות חוזיות והן גם ניתנות להעברה, הגם שהן שייכות לכלל בעלי הדירות בבית.

בעלים במשותף של זכויות בנייה רשאים לוותר עליהן ולהעבירן לאחר, ראו: ע"א 432/83 **מזרחי נ' חביב** פ"ד מ' (4) 673, וכפי שנקבע בעניין שטרייכר לעיל.

כמו כן, ניתן לבצע את חלוקת זכויות הבנייה על דרך של רישום הצהרה בתקנון הבית המשותף.

האם ניתן להצמיד או לשייך זכויות בנייה?

42. על פי סעיף 62 לחוק, ניתן להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולהצמידם למי מהדירות. אך מהו מצב הדברים, מקום משלא מדובר בשטח פיזי, אלא בזכויות? קיים קושי להגדיר זכויות בניה כ"צמודות" למי מהדירות, אם כי אין ספק כי ניתן לשייך אותן לדירה מסוימת (בהסכמה).

השימוש בביטוי "הצמדה" מקובל ביחס ובהקשר לחלקים הפיזיים של הבית ונועד להבהיר כי החלק הרלבנטי אינו משמש עוד כרכוש משותף, אלא הוא חלק מהדירה אליה לה הוא שייך.

במובן דלעיל, אין קושי אפוא, להתייחס לזכויות הבניה כ"צמודות" ליחידה מסוימת קרי: שייכות לה ולה בלבד (ולעיתים ניתן להסכים גם על הצמדה ליותר מדירה אחת, לדוג': כל זכויות הבניה שניתנות לניצול על הגג יוצמדו לדירות הגג וכיו"ב).

43. במסגרת תיקון 18 לחוק, נקבע כי: **"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה."**

ובכך יש חיזוק למסקנה כי זכויות הבניה בבית משותף הן "נכס סחיר".

סיכום ביניים מביא למסקנה לפיה זכויות הבניה שייכות ככלל לכל בעלי הדירות בבית המשותף, אולם התניה חוזית לרבות בתקנון מאפשרת לבעל דירה לוותר על זכותו לבנייה על פי חלקו ברכוש המשותף ולהעניקה לאחר [ראו דעת כב' השופט טירקל בע"א 10322/03 **ישעיהו נ' שטרייכר** (נבו, 23.3.05)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האם במסגרת הבית המשותף נושא ההליך הוחלט להצמיד זכויות בנייה לדירת התובעים ואם כן, באיזה היקף?

מערכות הכללים החלות על הבית המשותף

44. מערכת היחסים בין בעלי דירות בבית המשותף מוסדרת באמצעות מספר מערכות כללים: הוראות חוק המקרקעין ותקנותיו, התקנון המוסכם החל על הבית, התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין והחלטות האסיפה הכללית של הבית המשותף. כמו כן, כפופים בעלי הדירות להחלטות נציגות הבית המשותף והמפקח על רישום מקרקעין.

45. סעיף 61 לחוק קובע כי:

"בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף".

46. כאמור, לבית המשותף תקנון מוסכם אשר נרשם בשנת 1982 בד בבד עם רישומו של הבית בפנקס הבית המשותפים.

סעיף 62 (ג) לחוק קובע כי: "תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן".

47. תקנון מוסכם הוא חוזה, פרי יצירתם והסכמתם של בעלי הדירות בבית (ע"א (מחוזי חי') 1589/05 מצר נ' גיטיס (נבו, ביום 14.6.2006), ומשכך, חלים עליו דיני החוזים, וככזה, מלאכת פרשנותו היא כמלאכת פרשנות של חוזה (ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול פ"ד (3), 389 (2000)).

48. נקודת המוצא לדיון היא, אפוא, כי התקנון הוא חוזה החל על הצדדים להליך שבפניו וכי יש לפרשו כדרך שמפרשים חוזים. משכך, יחולו הוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"), וכן ההלכות הרלוונטיות.

49. סעיף 25 לחוק החוזים קובע כי:

"(א) "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.

(ב) חוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל."

50. משנתגלעה מחלוקת בין הצדדים באשר לשאלה כיצד יש לפרש את הוראות התקנון בענייננו אזי יש להתחקות אחר אומד דעתם העולה מתוך התקנון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מן הכלל אל הפרט

51. המחלוקת שנתגלעה בין הצדדים נוגעת לפרשנות ס' 2ב לתקנון.

52. סעיף 2ב לתקנון קובע:

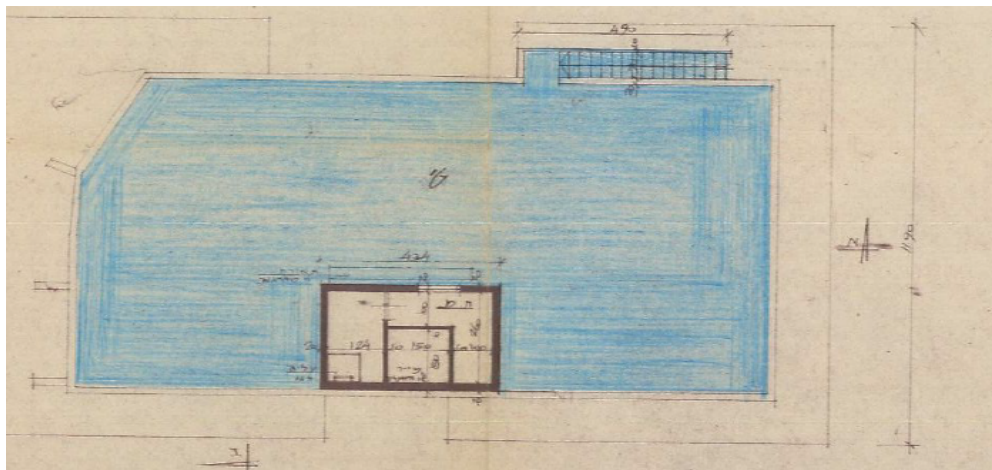
1. "הבעלים של המקרקעין מסכימים בזה כי בעל דירה מספר משנה 247/7 יהא רשאי לבנות ו/או להקים על שטח הגג הצמוד לדירתו והמסומן בתשריט באות ט' כל מבנה שהוא, לרבות בריכה, ובלבד שיקבל לכך היתר כחק, ללא כל צורך בקבלת הסכמת בעלי הדירות האחרות בבניין.

2. הזכות היא הן לגבי שטח הגג הצמוד לדירתו והמסומן בתשריט באות ט', ואם יבנו חדרים על שטח גג זה, הזכות היא גם לגבי גגות החדרים.

3. הבעלים של שטחי הגג המוצמדים יהיו רשאים לעשות בגג כל שימוש שהוא ובלבד שלא יהיה הדבר בניגוד לחק.

4. אחרי שתיבנה תוספת על הגג- יהיה הגג החדש שמעל לתוספת צמוד לדירה מספר משנה 247/7". ההדגשות אינן במקור – דק"ב.

53. לצד הוראה זו יובא להלן גם חלק מתוך תשריט הבית המשותף המדגים את ההצמדה הרלבנטית:



54. אין מחלוקת כי הגג המסומן באות ט' וצבוע בצבע כחול הוצא מהרכוש המשותף והוצמד לדירת התובעים כפי שנקבע בתקנון.

בע"א 136/63 לוינהיים נ' שוורצמן פ"ד י"ז 1722, 1724, נקבע: "חושבני כי איש לא יוכל לחלוק על הדעה כי ההצמדה בלבד של גג לאחת הדירות אינה נותנת את הזכות לבעל הדירה לבנות על הגג כעולה על רוחו, בלי הסכמת בעלי הדירות האחרות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית. הצמדת הגג אינה עושה אלא זאת שהוא חדל להיות רכוש משותף והופך להיות חלק מהדירה, אך עשיית שינויים ותיקונים על ידי בעל דירה בכל חלק של דירתו אינה אפשרית אלא בהתאם להוראות החוק".

אולם, שונה המצב שעה שקיים הסכם (ובעניינו תקנון) לפיו הוענקה לאחד מבעלי הדירות גם הזכות לבנות על הגג שהוצמד לדירתו וזאת כפי שנקבע בע"א 749/76 יוסף נ' בכר פ"ד ל"ב (3), 617, 621.

55. במיושם לעניינו, לא רק שהגג המסומן באות ט' הוצא מהרכוש המשותף אלא אף הותר לבעליה של אותה דירה לבנות עליו.

בע"א 5043/96 גלמן נ' הררי (נבו, 18.07.00), נקבע: "הדעת נותנת כי ההיתר שניתן בתקנון לבעלי הדירה לבנות על הגג הצמוד לדירתם כולל בחובו אף הסכמה לשימוש באחוזי הבנייה של הבניין. ראו ע"א מזרחי בעמ' 680. ואולם, אין בכך להשיב לשאלה אם ההסכמה לבנייה מהווה אף הסכמה לניצול כל אחוזי הבנייה שנותרו לבניין, גם אם הם עולים על אחוזי הבנייה הנדרשים לבניית קומה אחת. כאמור, לאחוזי הבנייה ערך כלכלי, וניצולם על ידי אחד מבעלי הדירות בבית המשותף מפחית את שווי הדירות האחרות. ככל שהניצול הוא מלא יותר, ההפחתה משווי יתר הדירות אף היא גדולה יותר. בנסיבות אלה, ההיגיון הכלכלי מחייב לפרש את ההיתר שניתן לבנייה על הגג הצמוד לדירה ככולל בחובו אך ורק את אחוזי הבנייה המספיקים להקמת קומה אחת. אף סביר להניח כי בעלי דירה בבית משותף המבקשים היתר לבנות על הגג הצמוד לדירתם מתכוונים להרחיב את דירתם, או למירב לנצל את הגג לבניית מבנה המשתרע על שטח כל הגג". (ההדגשות שלי – דק"ב).

בדומה לפסק הדין בעניין גלמן לעיל, גם בעניינו ניתנה לבעלי הדירה הרלוונטית הזכות לבנות על הגג ומכאן שיש לפרש את הצמדת הגג ככוללת את זכויות הבנייה הניתנות לניצול לגביו. עוד אציין כי בשונה מפסק הדין הנ"ל, ניתנה לבעלי הדירה גם הזכות להוסיף ולבנות גם על גבי הגגות החדשים שיווצרו. דהיינו: לבעלי הדירה הוענקה הזכות להוסיף ולבנות על הגגות העתידיים ולא הוגבלה לבנייה של קומה אחת בלבד. משכך, בשונה מפסק הדין הנ"ל מדובר, לדעתי, בהענקה של זכויות בנייה נרחבת לה הסכימו בעלי הדירות.

56. הנה כי כן, עינינו רואות כי המונח "זכויות בניה" אמנם אינו נזכר במפורש בתקנון. עם זאת, בעלי הדירות הסכימו ובאופן רחב יחסית ליתן לבעליה של דירת התובעים את הזכות לבנות על הגג הצמוד ט' "כל מבנה שהוא" וכן לבנות על גגות החדרים שיווצרו ולהצמיד אל הדירה גם את הגג החדש שיווצר.

57. לשון ההסכם היא לשון מרחיבה וכוללת שימוש בביטויים מרחיבים כגון: "כל מבנה שהוא", "לרבות" כאשר התנאים היחידים העולים מן התקנון הוא שהבניה תהא על גבי הצמדה ט' (ולא על גבי הגג המהווה רכוש משותף) וכן הצורך לקבל היתר בניה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כחוק. דהיינו : מלשון התקנון עולה כי ככל שבעלי הדירה יוכלו לקבל היתר בניה כדין על הצמדה ט' – כלומר, יעמדו בתנאי חוק התכנון והבניה והתכנית הרלבנטית אזי אין צורך בקבלת הסכמת בעלי הדירות האחרות בבית לבניה שכזו.

58. אני סבורה כי נוסח התקנון מלמד כי בעלי הדירה הרלבנטית רשאים לבנות על הצמדה ט' (ועל הגגות שייווצרו לאחר הבניה) ובכלל זאת לנצל את זכויות בניה לשם כך (גם אם אלו מצויות לכאורה בבעלות משותפת) שכן הסכמת בעלי הדירות לכך נתונה מראש. זוהי לדעתי משמעות אומד דעת הצדדים, ההגיוניות הסבירה וההולמת את הנסיבות המתיישבת עם לשונו.

59. עם זאת, כפי שעיננו רואות מאחר שקיים על גבי הצמדה ט' חדר (מכונית) אשר הגג שמעליו (בהעדר התניה מפורשת אחרת) מהווה "רכוש משותף" (שכן הגדרת הרכוש המשותף בחוק היא "שירות" כל מה שאינו "דירה" או "הצמדה" מהווה רכוש משותף) אין מדובר בהצמדת כל זכויות הבניה העתידיות (כפי דרישת התובעים) אלא כפי שיוסבר להלן.

60. אני סבורה כי לדירת התובעים הוצמדו כל זכויות הבניה באשר הן אלא אך זכויות בניה אותן ניתן לממש על ההצמדה הנ"ל או על הגגות שייווצרו בעקבות בניה עליה. רוצה לומר : ככל שתכנית מסוימת מאפשרת לבעלי הדירות להרחיב את דירותיהם או לבנות על שטח החצר/הקרקע או על הגג המהווה רכוש משותף, אזי זכויות בניה אלו שייכות לכלל בעלי הדירות כפי חלקם היחסי ברכוש משותף.

61. לגישת הנתבעים, משלא הוענקו לתובעים מלוא זכויות הבניה, בלשון מפורשת, אזי לדידם יש להסיק כי זכויות הבניה שהוקנו להם הן בגדרי חלקם היחסי ברכוש המשותף בלבד. אין בידי לקבל פרשנות זו של הנתבעים, שכן זו, לדעתי, מנוגדת להלכה שנקבעה בע"א 749/76 יוסף נ' בכר פ"ד ל"ב (3) 617, הנזכרת גם בפסק הדין בעניין ע"א 7156/96 שואעי נ' בכרך, פ"ד נ"ג (1) 469, ולפיה: "משהתירו בעלי הדירות בבית המשותף לבעל דירה לבנות בחלקת הרכוש המשותף בנתון להגבלות דיני התכנון והבניה, ולא כפפו את רשותם לכל הגבלה אחרת, ניתן להסיק משתיקתם כי הרשו לבעל הדירה לנצל את כל אחוזי הבניה הנדרשים לביצוע הבניה לפי ההיתר שניתן לו".

62. בעניינינו, לא הותר לתובעים לנצל את זכויות הבניה בכל רחבי הרכוש המשותף אלא אך על גבי הגג הצמוד להם ועל הגגות שייווצרו. משכך, אני סבורה כי המגבלה שהוטלה על התובעים היא השגת היתר בניה וזאת בהיבט התכנוני בלבד לשם כך, הואיל והסכמת בעלי הדירות בהיבט הקנייני לשימוש בזכויות הבניה לצורך האמור נתונה להם על פי התקנון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

63. אני סבורה כי כל פירוש אחר לתקנון לא יהלום את ההיגיון הכלכלי הגלום בו שהוא מתן אפשרות לבעלי דירה 7 לנצל את מלוא זכויות הבנייה הניתנות למימוש על הגג/ות הצמוד (או הניתנים להצמדה) הרלבנטיים.

64. לו כוונת הצדדים היתה כי התובעים יוכלו לנצל רק את חלקם היחסי בזכויות הבניה בלבד ספק אם הם היו נזקקים להעלות זאת על הכתב. עצם העובדה שבעלי הדירות התיירו לבעלי דירה 7 לבנות גם על הגג הצמוד וגם על הגגות שיווצרו מלמדת על כוונת הצדדים הרלבנטיים לוותר גם על זכויות בניה עתידיות ולהצמיד לדירה 7 את זכויות הבניה הניתנות למימוש בחלק זה הבית הן נכון למועד חתימת התקנון והן בעתיד.

אין בידי לקבל את הטענה שאת ההסכמה שגלומה בתקנון יש לפרש כתלויה ביכולת ניצול אחוזי הבניה בעת רישום התקנון. האפשרות שאחוזי הבניה יוגדלו בעתיד היא מקרה צפוי במציאות ארצנו. אני סבורה כי עצם העובדה שבעלי הדירות הקנו לבעלי דירה 7 את הזכות לבנות גם על גבי גג החדרים שיווצרו, כהסכמה המלמדת על ויתור על זכויות עתידיות במובן זה. רוצה לומר: ככל שניתן לנצל זכויות בניה עתידיות על גבי הגג הצמוד או על הגגות הצמודים שיווצרו, אזי אלו שייכים לדירת התובעים. אפנה בעניין זה לע"א (ירושלים) 25959-05-10 **שפירא לוי נ' שלומית יקיר** (נבו, 22.3.2011).

גם בענייננו, כפי שנקבע בפסק הדין הנ"ל, דירה מס' 7 הייתה בבעלות הקבלן (מרדכי דינוביץ') והתובעים רכשו את הדירה מאת רעייתו. יש להניח, כי הקבלן ביקש לשמור בידיו את האפשרויות העתידיות לניצול זכויות באופן מיטבי, ולכן, אני סבורה שיש לפרש את התקנון באופן רחב ובהתאמה ללשונו.

65. בעלי הדירות רכשו את דירותיהם שעה שהתקנון המוסכם היה ידוע ולכן זכויותיהם כפופות לאמור בתקנון.

1. סיכום

66. אשר על כן, ככל שבעלת הדירה הרשומה או מי מטעמה יחתמו על הבקשה להיתר הנוגע לניצול זכויות בניה על גבי גג ט' או הגגות שיווצרו בעקבות בניה עליו, לא נדרשת לשם הסכמת יתר בעלי הדירות לבניה זו.

67. אני קובעת כי מבחינה קניינית שימוש בעלי דירה 7 בזכויות בניה שניתן לממשן על גבי גג ט' אינה מצריכה את קבלת הסכמת יתר בעלי הדירות באשר זו נתונה להם מראש בתקנון המוסכם.

68. ככל שמוסד התכנון יעמוד על חתימת יתר בעלי הדירות על גבי תכנית הבניה אני מסמיכה בזאת את ב"כ התובעים עו"ד צביקה צ'יפוק מרח' גולדנהירש 24 פתח תקווה לחתום בשמם של הנתבעים על הבקשה להיתר ועל כל המסמכים הרלבנטיים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/795/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וזאת בתנאי שהבניה תתייחס לנכסים הרלבנטיים בלבד (ולא על גבי הרכוש המשותף).

69. משהתקבלה התביעה זכאים לכאורה התובעים להוצאותיהם.

נק' המוצא לדיון בעניין הוצאות היא כי בעל דין שזכה בדין זכאי להוצאותיו הראליות, כשהכוונה היא להוצאות שהוציא בפועל (או התחייב להוציא).

עם זאת, על היושב בדין לשקול אם שיעור ההוצאות הנטען סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו (ראו בג"צ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הרשות המוסמכת** (30.6.2005, נבו)).

בין השיקולים שעל היושב בדין לשקול הם התנהגות הצדדים להליך, דרך ניהולו, מורכבות התיק ועוד.

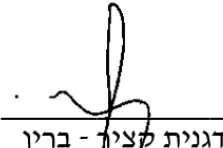
70. לא הוצגו בפני אסמכתאות ביחס להוצאות הצדדים.

אמנם, תביעת התובעים התקבלה, אך היא לא התקבלה במלואה (שכן, כפי שהוסבר לעיל התובעים נסוגו במהלך ניהול ההליך מדרישתם ורצונם להקמת יחידה נוספת בבית). כמו כן, פסק הדין "מחדד" כי זכויות הבניה השייכות לתובעים הן זכויות הבניה הניתנות לניצול על גבי הגג הצמוד ט' (וגגות נוספים שיווצרו אך לא ביחס לגג המהווה רכוש משותף). את האמור לעיל יש לזקוף, לדעתי, לזכות הגנת הנתבעים.

אשר על כן, אני סבורה כי בנסיבות ההליך והעניין, על כל צד לשאת בהוצאותיו.

71. העתק מפסק דין זה, יישלח לרשות מיסוי מקרקעין, אשר תשקול בחינת טענות הנתבעים לפיהן מכר זכויות הבניה מאת בעלי הדירות אל מר דינוביץ' ומגב' דינוביץ' אל התובעים, לא דווח כנדרש (נושא שאינו מצוי בתחום סמכותי העניינית).

ניתן היום ד' כסלו תשפ"ג (28 נובמבר, 2022) בהיעדר הצדדים. עותק יומצא.


דגנית קציר - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו